



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 33/13

בענין :

1. הולנד אילנה
2. מורבסקי ניבה
3. רחל ארנון (הרשקוביץ)
- יצחק ארנון (הרשקוביץ)
4. צדבאום לנקה (הלנה)
5. הולצר יפה
6. עמוס לניר
7. רוזנברג דבורה (דורותי)
8. חביבה פרי
9. רביד יוסף
10. יצחק פרנקל
11. תמי מנור
12. נציגות הבית המשותף

כולם ע"י ב"כ עו"ד אסיא סיוון ואח'
משד' המגינים 44, חיפה 33246
טל': 04-8552292, פקס: 04-8552112

התובעים

נ ג ד

יקים נוגה
ע"י ב"כ עו"ד יגאל זאבי ואח'
מרח' שיבת ציון 21, חיפה
טל: 04-8622990, פקס: 04-8253347

הנתבעת

פ ס ק - ד י ו

1. התובעים שהם נציגות הבית המשותף וכן בעלים של מספר דירות בבית המשותף עתרו למתן צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעת, שהיא הבעלים של אחת מדירות הבית המשותף, להרחיב את דירתה; כן עתרו התובעים למתן צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעת להשתלט ולתפוס באופן ייחודי חלקים מחצר הבית לרבות על דרך של הקמת מרפסת /ריצוף או גידור, ו למתן צו עשה אשר יורה לנתבעת לסגור פתח יציאה מדירתה אל החצר ויורה לה לסלק את מיטלטליה מהרכוש המשותף.

2. הבית המשותף נושא ההליך נמצא ברח' התשבי 110-84 חיפה, מזוהה כחלקה 21 בגוש 10812 ומכיל 7 מבנים בהם 52 דירות (להלן: "הבית/הבית המשותף"). דירת הנתבעת היא דירה תחתונה ב מבנה שמספרו 110 ודירות התובעים מצויות במבנים השונים של הבית המשותף.

טענות התביעה-

3. המדובר במתחם ייחודי אשר נבנה בשנות ה- 50 ע"י ה ארכיטקט הידוע מוניו גיתאי וינרויב . המתחם תוכנן ונבנה בצורה ייחודית , תוך התחשבות בתכנון האתר והמרחב , שיפור הפרטיות ואפשרות פתיחת חלונות בכל דירה ל-4 כיווני אויר.

4. בשנת 2010 או בסמוך לכך רכשה הנתבעת את דירתה וביצעה בה שינויים לרבות פתיחת פתח יציאה אל שטח החצר המשותפת, ללא שקיבלה לכך הסכמות יתר בעלי הדירות בבית (מראש או בדיעבד).

5. על אף התנגדות שכניה הגישה הנתבעת לוועדה המקומית לתכנון ובניה בקשה להיתר בניה ל הכשרת הפתח שפתחה , לבניית דק עץ ולהרחבת הדירה לצורך בניית ממ"ד. כבר בפרק זה אקדים ואציין כי היות והנתבעת הודיעה בכתב הגנתה כי לאור התנגדות השכנים היא חוזרת בה מרצונה להקים דק עץ לא מצאתי להתייחס עוד בפסק דיני זה לאותו משטח.

6. באשר לממ"ד - הנתבעת נעדרת את הרוב הדרוש עפ"י חוק להרחבת דירתה היות ולפחות 25 בעלי דירות במתחם הביעו התנגדות מפורשת לבניה וגם יתר בעלי הדירות לא נתנו הסכמה מפורשת או בכתב.

7. בניית הממ"ד תפגע מהותית בצביון הייחודי של המתחם , בערכי הטבע , בנוף ובאדריכלות המיוחדים שלו . מנגד אי היענות לנתבעת לא יפגע בה היות וקיים מקלט במבנה בו מצויה דירתה ובסמיכות יתרה לדירה . זאת ועוד , הנתבעת רשאית לחזק חדר בדירתה ללא צורך בקבלת הסכמות וללא שתפגע בחזות הבית. היענות לבקשת הנתבעת לבנות ממ"ד תביא לכך שכל בעל דירה במתחם יוכל להרחיב דירתו ובכך תפגע ייחודיות המתחם . נימוקי התנגדות אלו אינם סתמיים ואינם עולים כדי התנגדות שאינה בתום לב , היות וחזות המבנה וייחודיות המתחם הם ערך עליו רשאים בעלי הדירות להגן.

טענות ההגנה-

8. המקום בו מבוקש לבנות ממ"ד אינו חוסם דבר למי מבעלי הדירות בבית, בהיותו מצוי באזור המוסתר בצמחיה ואינו נראה לעין מדירות התובעים . פני הקרקע עליה בנוי הבית משופעים, משכך, הממ"ד לא יראה לא לבעלי הדירות במבנים המצויים במעלה החלקה ולא לבעלי הדירות המצויות במורד חלקה.

9. בדיון שהתקיים ביום 8.4.13 הגיעו הצדדים להסכמה ולפיה הנתבעת נעדרת את הרוב הדרוש לבניית ממ"ד עפ"י חוק המקרקעין , התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). ואולם, כבר נקבע בפסיקה כי גם המקום בו נעדר הרוב הדרוש לפי

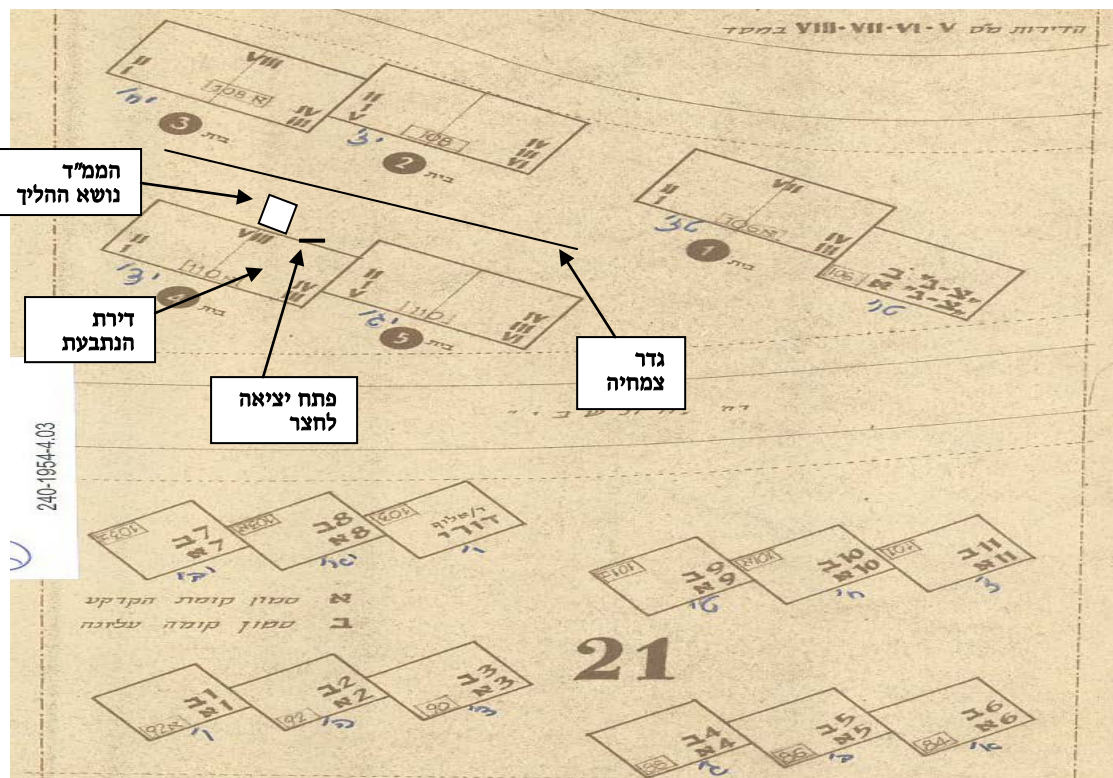
סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין יש לבחון את התנגדות המתנגדים לגופה, לאמור, האם עולה היא בקנה אחד עם דרישות תום הלב החלות גם על דיני הקניין.

01. הוועדה המקומית לתכנון ובניה קיימה ביקור במקום, בחנה את טענות התובעים לפגיעה ארכיטקטונית והביעה שביעות רצון מהמיקום המוצע לבניית הממ"ד ואישרה את הבקשה לבנייה. המתחם מעולם לא הוכרז כמתחם לשימור ואף לא הוגשו כל בקשות או תוכניות להכירו ככזה.

11. תביעת התובעים נגועה בחוסר תום לב היות ועיקר טענות התובעים הם שאין לאפשר כל שינוי או תוספת לבית המשותף בהיותו מבנה ייחודי. טענה זו אינה עולה בקנה אחד עם העובדה שחלק מהמתנגדים שינו את דירותיהם, וגם לא עם העובדה שמקצת התובעים הביעו רצונם לבנות ממ"דים לכולם.

ההליכים בתיק-

21. ביום 6.6.13 קיימתי ביקור המקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהמקום. טרם שאסקור את ממצאי הביקור במקום, ועל מנת להקל על הבנתם, מצאתי למזג בפסק דיני חלק מתשריט רישום הבית המשותף אשר נרשם ביום 4.3.54. על גבי התשריט הוספו הערותיי וכן סימונים נוספים שלא נערכו עפ"י כללי מדידה תקינה אלא נעשו על ידי במיקום משוער לשם הבהרה והמחשת המיקום המופיע בטיעוני הצדדים בלבד.



37. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך :

(א) בתוך חלקה 21 עובר רח' התשבי באופן שהוא מחלק את החלקה לשני חלקים. בחלקה העליון של החלקה מצויים מספר מבנים (מסומנים במספרים 84-103 בתשריט לעיל), ובחלקה התחתון של החלקה מצויים מבנים נוספים (מסומנים 106-110 בתשריט לעיל). דירת הנתבעת מצויה בקומת הקרקע של המבנה המסומן כ-110.

(ב) מדובר בחלקה שניכר כי הזמן עצר בה מלכת. הבתים אחידים, מחופים בגגות רעפים אדומים, הרחבות בניה או שינויי חזיתות אינם נראים בשטח, המתחם כולו טובל בירק והצמחייה הינה חורש טבעי רב שנים. אל הבתים מגיעים בשבילי מדרגות ואין כניסת רכבים למתחם. חניית רכבים נעשית ברחוב.

(ג) המרחק בין המבנים רב ובין המבנים מפרידות מעין גדרות צמחיה המקנות פרטיות נוספת לכל מבנה.

(ד) הממ"ד המוצע אמור להיבנות בעורף המבנה בו מצויה דירת הנתבעת. עפ"י התרשמותי הממ"ד כמעט ולא ייראה מהמבנים האחרים בחלקה; היות ומהמבנים הבנויים במעלה החלקה לא ייראה הממ"ד בהיותו מצוי מאחורי המבנה בו מצויה דירת הנתבעת, ומיתר המבנים לא ייראה בהיותו מוסתר ע"י הצמחייה הקיימת במקום. במצב הדברים הנוכחי - היחידים שיכולים יהיו לראות את הממ"ד הם בעלי הדירות המצויות באותו המבנה בו מבוקש לבנות את הממ"ד.

(ה) בדירת הנתבעת נפתח פתח יציאה לחצר. המדובר בחצר שתחומה במרבית פאותיה באמצעות צמחיה רבת שנים והגישה אליה אפשרית בעיקר לבעלי הדירות במבנה נושא ההליך.

47. ביום 5.11.13 התקיים דיון הוכחות בו העידו מטעם התביעה ארבעה בעלי דירות בבית, ומטעם ההגנה העיד אביה של הנתבעת. חלקים מהעדויות יובאו בפרק הדיון. הצדדים הגישו סיכומי טענות בהם חזרו על עיקר טענותיהם לעיל.

דיון והכרעה-

57. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ככל שהיא נוגעת למתן צו אשר ימנע את בניית הממ"ד ולדחות את יתר הסעדים המבוקשים. הכל כפי שיפורט להלן:

67. הוראות הדין בגדרן מוסדרת זכותו של בעל דירה להרחיב את דירתו תוך מימוש זכויות בניה קבועות בסעיפים 71א-ד' לחוק המקרקעין. בסעיף 71א' מוגדרת הרחבת דירה כ"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה

היתר בניה לפי תכנית בת תוקף " . סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין מתנה את הזכות להרחבת דירה אגב מימוש זכויות בניה לשם בניית ממ "ד בתנאי אחד ויחיד : "...היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי , רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות" (הדגשה שלי י.ל.). מתחייב מכאן שעל הנתבעת נטל הראיה להתקיימות התנאי של הסכמה של 60% מבעלי הדירות לבניה המתוכננת על ידה , שכן רק לרוב כזה יש את הזכות לכפות דעתו על מיעוט המתנגד לבניה.

71. יש לזכור כי הוראת החוק החליפה את המצב המשפטי שקדם לה , לפיו רק בהסכמה של כל בעלי הדירות ניתן היה לבצע בניה ברכוש המשותף , ראו סעיף 62(א) לחוק המקרקעין וכן ראו סעיף 2 (א) לתקנון המצוי . המחוקק היה ער לקושי הנעוץ בכך שאוסף של פרטים , שכולם משיאי אינטרס עצמי , שהשאת האינטרס העצמי שלהם מחייבת שיתוף פעולה , עשויים - בהיעדר כפייה משפטית - לא להצליח לאחד כוחות על מנת להשיג את מטרותם . במצבים שקידום האינטרס המשותף מחייב בהם השתתפות של כולם , צפוי שפרטים ינסו לנצל את עמדת המיקוח המיוחדת שהצורך בהשתתפותם מקנה להם , על מנת לנסות לגרוף לכיסם הפרטי חלק גדול ככל האפשר מהיתרונות ששיתוף הפעולה הקבוצתי עתיד להצמיח . לאור זאת , חוקק תיקון 18, ובדומה לו חוקקו תיקונים נוספים ן כדוגמת תיקון 19 הדין בהקמת מעלית משותפת ברכוש המשותף , תוך ביטול זכות הוטו שהייתה נתונה לכל בעל דירה בבית וקבעו כי מלכתחילה יהא דרוש רוב מופחת תוך הוספת תנאים ואיזונים כמו תשלומי איזו ן , שמירת הזכות לבנות סוכה , זכות ההתנגדות של מי שנפגע מקבלת החלטה וכו' . ראה דגן , ' קניין על פרשת דרכים' (תשס"ה-2005), עמ' 405, 415.

81. קניין הוכר בדין כזכות יסוד הראויה להגנה . דיני הקניין במשפט הפרטי , ובמקרה הזה חוק המקרקעין , הם שקובעים את הקריטריונים להגנה על זכ ן ות זו . דויטש בספרו קנין , כרך א' , עמ' 701 בוחן אחת לאחת את תנאי סעיף 8 לחוק יסוד : כבוד האדם וחירותו נשמרים בתיקון 18 לחוק המקרקעין ומוצא כי התיקון תקף. בע"א (חי) 1725/05 **דוד נ' נברוצקי** פרש בית המשפט את תכלית הוראת החקיקה האמורה וקבע כי :

"תיקון 18 לחוק המקרקעין ביקש כעולה מדברי ההסבר שפורסמו בהצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש משותף) תשנ"ה-1994, לאפשר שינויים ברכוש המשותף בבית המשותף, בגדר הגמשה מסוימת של הדין בעניין זה ששרר עד אז , בגדרו בניה על רכוש משותף לטובת בעל דירה היתה ט עונה הסכמת הכל (ראו למשל ע"א 2111/03 פליצ'ה ואח' נ' סופיוב ואח' פסק דין מ- 22.3.05 תק-על 2005(1)3589). תכלית התיקון היתה לאפשר הרחבת דיור תוך הפחתת כוחו של המיעוט למנוע אותה בגדר מגמה כללית לאפשר ניצול טוב יותר של הקרקע ... סימן ג'1 לחוק המקרקעין שיוחד לענין שינויים

**ברכוש המשותף ובזכויות בניה כולל בחובו איזונים שונים הבאים
להבטיח כי הפגיעה בבעלי דירות המיעוט לא תהיה מעבר לנדרש..."**

91. אמור מעתה : הזכות להרחיב דירה אגב מימוש זכויות בניה לצורך בניית ממ"ד מצריכה הסכמה למצער של ששים אחוזים מבעלי הדירות . הוראת החוק בסוגיה זו היא ברורה וחד-משמעית, אין היא מותירה פתח לפיחות בתנאי שהיא קובעת . לשון החוק בסעיף 71ב(א) ברורה וחד משמעית, לשם קבלת אישור להרחבת דור לצורך בניית ממד " צריך להתקיים התנאי הזה (ראה בענין גם אייזנשטיין , ייסודות והלכות בדיני מקרקעין', 213).

02. יחד עם זאת, לפי הפסיקה, נקבע גם כי קיימת חובה לממש זכויות בדין , לרבות זכויות קנייניות , בתום לב. כך מורה אותנו סעיף 14 לחוק המקרקעין וכן רא ו הדיון המקיף במונח זה ברע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון** פ"ד נה (1) 199. יתרה מכך, לבעל זכות קניינית אין את החרות להתנגד לכל מיזם של שכנו באופן סתמי ונטול הנמקה , ראו התייחסות בית המשפט ב ע"א (חי) 835/08 **נטלה נ' פרי** מיום 18.11.09 (להלן :פס"ד נטלה"). ואולם, על הנתבעים כמי שמהווה מיעוט להוכיח שהתנגדות התובעים הינה סתמית וקנטרנית , ראו ע"א (חי) -13877-04 מיום 09 **קיסרי נ' שלומוב** מיום 16.8.10, וראו גם עש"א (חי) 17181-05-11 **אברהם נ' פדאל** מיום 20.9.11, וכן עש"א (חי) 36004-06-12 **פלאוט נ' הוד** מיום 7.6.13. התייחסות מפורטת יותר בעניין סוגיית תום הלב והדברים שנאמרו לגביה בפסקי דין אלו תובא להלן.

מן הכלל את הפרט-

12. לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי לנתבעת לא עומד הרוב הדרוש לפי חוק לשם הקמת ממ"ד, והצדדים הסכימו כי הפלוגתא בתיק היא השאלה האם התנגדות התובעים נעדרת תום לב, והאם היא גוברת על דרישת הרוב הנחוץ לפי סעיף 71ב לחוק המקרקעין . ראו ההסכמות כפי שנרשמו בפרוטוקול הדיון מיום 8.4.13 בעמ' 2.

22. שני הצדדים סמ כו ידיהם בסיכומיהם על אותו פס"ד. המדובר בפס"ד נטלה שלהלן, אשר כל צד מצא בו תימוכין לעמדתו . התובעים ציטטו ממנו את החלק הקובע כי : **"חזות המיוחדת של הבית היא עניין שיש לו ערך , וזכאים בעלי הדירות בבניין להבטיח שמירת ערך זה."** לטעמם, מקום בו התנגדותם נסמכת על הטענה כי הבניה תפגע בחזות המתחם , אחידותו וייחודיותו לא ניתן לראות בכך התנגדות שאינה בתום לב.

הנתבעת מנגד, סמכה ידיה על אותו פס"ד דין תוך שביקשה לקבוע מכוחו כי : למפקח על רישום מקרקעין סמכות לבחון את נימוקי ההתנגדות לגופם אפילו לא קיים לה הרוב הדרוש . אליבא דידא של הנתבעת , התובעים טוענים כי בשם הרצון לשמר את המתחם ולא לפגוע במראהו האחיד ו הייחודי הם מתנגדים לבניה, אך טענתם זו אינה עולה בקנה אחד עם העדויות של עדיהם מהם עלה כי

ככל שתהיה תוכנית כוללת לבניית ממד "ים במתחם כולו" ישקלו מתן הסכמתם לה.

32. נדרשת אני כעת להכריע בשאלה האם התנגדות התובעים עולה כדי חוסר תום לב או כדי התנגדות לגיטימית.

טרם שאקבע האם יש חוסר תום לב בהתנגדות התובעים אסקור להלן מקצת מעדויות הצדדים באשר לנימוקי התנגדותם לבניה:

העיד תובע מס' 10 בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 5-12:

"אחת הסיבות העיקריות שהתאמצתי לר כוש את הדירה, מחצית הדירה, אחרי שאבי נפטר היא שאני אוהב את המקום, למרות שאני לא גר שם. אני רוצה שהמקום ישמור על הצביון שלו. זה דבר נדיר שבסביבה עירונית יש מקום שנראה כך. אפשר להיות במרחק של חמש דק' ה הליכה ממרכז הכרמל ולהימצא בסביבה שהיא כמעט כפרית. אני יודע שהמקום תוכנן כפרוייקט אחד עם אופי מסוים ועם תכנון מסוים על ידי אדריכלים שבשעתו היו מהידועים בארץ. מקום זה ראוי היה להיות מוכר כאתר לשימור. אני חושב שכל בניה בשטחים הפתוחים תפגע בצביון שלו."

תובע מס' 9 העיד בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 35-41:

"חיפשתי הרבה זמן דירה מתאימה לעבור אליה. ראיתי הרבה דירות. כאשר ראיתי את הדירה בשכונה הזו זה מצא חן בעיניי השילוב שלה שהוא די נדיר של ריאות ירוקות בצורה ברורה והמרחקים שבין הבניינים וגם הצורה של הבניה הסביבתית. זאת אומרת לא כל מיני בניינים שונים אחד מהשני אלא זה קצת הזכיר לי את שויעריה. לכן הגעתי לשם. אני לא רוצה שיהיו שינויים לא על חשבון החלק הירוק ובכלל אני לא מעוניין שמעבר למבנה עצמו של כל בניין תהיה תוספת. זה לא מתאים למה שאני רוצה."

תובעת מס' 2 העידה בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 38-41:

"מי שרואה את השיכון יכול להבין איפה אנו יושבים ואין צורך להמשיך לספר. אנו משתדלים גם לעשות שזה יישאר כמו שהיה כל הזמן. השטח קיים כבר 50 ומשהו שנים, ואני עוסקים בשימור שלו. כל שינוי יפגע ויוריד את איכות חיינו. אנו גרים בפנינת חמד ורוצים להמשיך לגור במקום כזה."

וראו גם עדות תובעת מס' 8 בעמ' 5 שורות 6-11.

מהעדויות גם עלה כי נעשה ניסיון לעריכת תוכנית כוללת ל כל המתחם אך זו לא קרמה עור וגידים. מקצת התובעים הביעו נכונות לשקול מתן הסכמה לתוכנית

כוללת אשר תיתן פתרון של בניית מ"דים בכל המתחם, אך בה בעת הסכימו כי קיים קושי אמיתי להביא כמות כה רבה של בעלי דירות לכדי שיתוף פעולה והסכמה על מתווה אחד.

42. האם התנגדות התובעים המונעת באופן עקרוני וספציפי כל יכולת להרחיב או לגדול אל מחוץ לגבולות המבנה והדירה מהטעם שברצונם לשמר את הבתים במתחם במצב הבניה נכון להיום עולה כדי התנגדות בתום לב לבניה?

52. בפס"ד נטלה נדרש בית המשפט לשאלת משמעות תנאי הסף שבסעיף 71ב(א) לחוק ולבחינה האם במקום בו נעדר בעל דירה הסכמות ברוב הדרוש תישלל לאלתר זכות הבניה ללא שתבחנה טענות הצדדים או שמא בית המשפט צריך להידרש לנימוקי ההתנגדות של הצדדים. בית המשפט הוציא מלפניו פסק דין ובו עמדות שלושת השופטים שישבו בהרכב לאמור:

כב' השופט זרנקין:

"אף כי לא על נקלה יתערב בית המשפט ויטיל סייגים על דרך מימושה של זכות הקניין על ידי בעליה הרי ניתן לחשוב בהחלט על מצבים בהם עמידה על קוצו של יוד במימושה של הזכות תיחשב כבלתי הוגנת, ואפשר ובית המשפט יתערב בה.

אף כי אפשר בהחלט והמקרה בו עסקינן איננו מסוג המקרים בהם ההתערבות נדרשת, ואפשר ובאמת טעמים אמיתיים וסבירים עומדים ביסוד התנגדותם של בעלי הדירות, לאפשר למערערת להרחיב את דירתה בתחומי הרכוש המשותף, הרי אין לומר שבאופן אפריורי כי אין להידרש לטעמים אלו כלל ועיקר".

כב' השופט כהן:

"במשטר שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, נתן המחוקק את הכוח בידי רוב בעלי הדירות "להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה". במילים אחרות, הרכוש המשותף מוגן ב"הגנה קניינית", ולצורך הסרת ההגנה, דרוש רוב מסוים שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין. הפועל היוצא מכך הוא, שמי שאינו מצליח לגייס את הרוב הדרוש, כמו המערערת שלפנינו, לא יוכל לקבל חלק מסוים מהרכוש המשותף לשם הרחבת דירתו.

סעיף 14 לחוק המקרקעין, עליו משליכה המערערת את יהבה, הוא סעיף הדדי. הוא חל על כל בעלי הרכוש המשותף באותה מידה. כשם שהמשיבים אינם זכאים לעשות שימוש בזכויותיהם הקנייניות, כשלעצמן, לשם גרימת נזק או אי נוחות למערערת, כך אף המערערת אינה רשאית לעשות שימוש בזכויותיה הקנייניות, כשלעצמן, לשם

גרימת נזק או אי נוחות למשיבים . סעיף 14 לחוק המקרקעין פועל לזכותה או לחובתה של המערערת , ממש כשם שהוא פועל (בהתאמה) לחובתם או לזכותם של המשיבים".

כב' השופטת וסרקרוג :

"יש לאבחן בין מיעוט שפונה בתביעה למפקח על רשום מקרקעין לפי סעיף 59ג(ד) לחוק המקרקעין ומבקש לבטל החלטת בניה של הרוב בנימוק של פגיעה מהותית בזכות קניינית שלו לבין מי שנעדר את הרוב הדרוש עפ"י סעיף 71ב(א) לחוק ומבקש חרף זאת כי תאושר לו הבניה : "בסעיף 59 ג(ד) של החוק , מדבר המחוקק על דרישה ל "טעמים בלתי סבירים". בענייננו, התייחסתי למונח התנגדות סתמית שעניינה כאמור, התנגדות בלתי הוגנת , בלתי ראויה ואשר יש בה כדי לפגוע בעקרונות יסוד של השיטה , התנגדות שאינה נוגעת למעשה לפגיעה בזכות הקניין ככזו, עד כדי שימוש לרעה באותה זכות".

62. סיכום עמדותיהם של כב' השופט זרנקין וכב' השופטת וסרקרוג מעלה כי טענת העדרו של הרוב הדרוש להוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה לשם בניה, כתנאי סף, לא תעמוד לבונה לרועץ מקום בו אינו מגיע לרוב הדרוש רק למול התנגדויות העולות כדי קנטור, עמידה על קוצו של יוד, בשל מוצא או מסיבות אחרות שנוגדות את עקרונות המשפט. להבדיל, אליבא דידו של כב' השופט כהן יש ליתן משקל ללשונו הברורה של סעיף 71ב(א) הקובע תנאי סף בדמות החלטה של 75% מבעלי הדירות שצמוד להם 2/3 מהרכוש המשותף או בהיקש לענייננו להסכמה של 60% מבעלי הדירות לצורך בניית ממ"ד.

72. גם בעש"א (חי') 13877-04-09 **קיסרי נ' שלומוב** ביקשה דעת הרוב להתיר את תנאי הסף האמור בסעיף 71ב' לחוק המקרקעין והקובע מהו הרוב ההכרחי לשם בניה בעינו, וסייגה את האפשרות של בית המשפט להתערב בשיקולי ההתנגדות של בעל דירה רק במקרים חריגים לאמור :

"זאת ועוד, נקודת המוצא לכל דיון בעניין בניה ברכוש המשותף הינה כי לאף אחד מהשותפים אין זכות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, תפיסה של הרכוש המשותף לשימוש ייחודי ובניה ברכוש המשותף, מחייבת קבלת הסכמתם של כל השותפים, ולמצער הסכמת הרוב כנדרש על פי הוראות סעיף 71ב' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969"

ובהמשך פסה"ד-

"אוסף, כי ראוי שבית המשפט יזהר פן ישים עצמו במקומם של בעלי הדין. עיקרון תום הלב אינו נועד להעביר לבית המשפט את שיקול הדעת מתי להסכים לבנייה ברכוש משותף, אלא רק לאפשר לו למנוע התנגדות של שכן מנימוקים פסולים."

82. בעש"א 17181-05-11 **אברהם נ' פדאל** מיום 20.9.11 ניתן פסק דין בערעור על פסק דינה של כב' המפקחת וינברגר (כתוארה דאז) אשר מצאה להתיר בניה גם

בהיעדר הרוב הדרוש לאחר שמצאה כי התנגדות בעלי הדירות הייתה נעדרת תום לב. ערכאת הערעור מצאה לקבל את הערעור שהוגש על פסק הדין ואלו נימוקיו מפי כב' השופטת וסרקרוג:

"שם (-בע"א 835/08 נטלה נ' פרי, הוספה שלי י.ל.) בדעת רוב נקבע כי אין בהגבלה שנקבעה בסעיף 71 לחוק המקרקעין כדי לאפשר למי מן המתנגדים לבוא לבית המשפט ולהתנגד מבלי להעלות את נימוקיו להתנגדותו (דעה חולקת, כבוד השופט כהן). במקרה דנן, גם על פי הדעה של הסמכות לבחון את נימוקי המתנגדים, סבור ההרכב שטענה כבוד המפקחת משסברה במסגרת סמכותה לבחון את הנימוקים כי יש לראות את אלה, כטעמים שהועלו שלא בתום לב וכי סמכותה של הרשות השופטת לבוא לשקול את השיקולים על ידי דה, במקום הדיירים האחרים. סמכות כזו אינה קיימת. בנסיבות העניין, אין לייחס העדר תום לב למערערים, והיה מקום לאשר התנגדותם למנוע הבניה.

לעניין הטענה כי יוצר מעין זכות וטו לדיירים בבניין הקדמי בנוגע לכל בנייה שיתבקשו הדיירים לבצע בבניין האחורי, יש להשיב, כי על רוכשי הדירות במבנה האחורי היה לקחת נתון זה בחשבון בעת הרכישה, ובכל מקרה, בדעת רוב (השופטים ש' וסרקרוג והשופט ר' שפירא) אם אכן תהיה התנגדות סתמית או נוגדת עקרונות שיטת המשפט, הסמכות של ביהמ"ש לבדוק את ההתנגדות עומדת בעינה אך אינה יכולה לבוא במקום הדיירים אלא על דרך בחינה נדרשת."

ובהמשך-

"בשאלה הראשונה שהיא עקרונית, אם לאור האמור בסעיף 71 לחוק המקרקעין שכותרתו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה" עומדת הזכות למתנגד שלא לפרט את נימוקיו להתנגדות, אפילו אלה סתמיים ואפילו נוגדים הם את עקרונות שיטת המשפט ותו לא, הלב- שהוא אחד מעקרונות היסוד בשיטה- סבורה הייתי וסבורה אני שאין לאפשר התנגדות ללא הנמקה. בשלב השני שלאחר הבאת הנימוקים סמכותו של ביהמ"ד לבוא ולבחון נימוקים אלה היא מצומצמת ביותר. אכן, אין לדעתי לאפשר התנגדות סתמית שאינה עניינית או שיש בה משום שימוש לרעה בזכות הקניין, כך נאמרו על ידי בפס"ד צבי והוספתי כדוגמא כאשר בעלים של מספר דירות בבניין מתנגדים מתוך כוונת קנטור או בשל "מוצא או נסיבות אחרות הנוגדות את עקרונות שיטת המשפט ואשר אין בהם דבר או חצי דבר עם הפגיעה הקניינית לכשעצמה..." (הדגשה שלי י.ל.)

92. סיכום הפסיקה בנושא מעלה כי, ככלל, נתונה למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לבחון את נימוקי ההתנגדות, קרי, התנגדות שאין נימוקים בצידה לא לתקבל. יחד עם זאת, דעתם של כל השופטים שישבו בדין הייתה כי יש לצמצם

סמכות זו ביותר, קרי, למפקח על רישום מקרקעין לא קיימת הסמכות לשקול חלף בעלי הדירות את השיקולים ולבטלם מקום בו דעתו שונה מדעתם.

ולענייננו-

03. לכשעצמי סבורה אני כי עקרון השמירה על חיי אדם חשוב מאין כמותו, וקיימת חשיבות ראשונה במעלה להוספת ממ"דים לדירות, גם בבתים בהם קיים מקלט, אשר ברי כי אינו נותן בעת חירום מענה דומה לממ"ד מבחינת קרבת המיגון.

אני גם סבורה כי שוגים בעלי הדירות במתחם זה עת מבכרים הם את קידוש עיקרון "האסתטיקה והשימור" בכל הנוגע למראהו של המתחם על פני מיגון של הדירות.

זאת ועוד, בביקור שערכתי במקום לא מצאתי כי יהיה בבניה האמורה כדי לפגוע במראהו של הבית או של המתחם, היות והממ"ד אמור להיבנות בעורף המבנה בו מצויה דירת הנתבעת באופן שכמעט ולא יראה משום כיוון, לא כל שכן לא יראה מאזור חזית הבית.

הוסף לכך את העובדה ש בדין טענה הנתבעת כי המתחם נושא ההליך לא הוכרז כמתחם לשימור, ואף לא הוגשו תוכניות המראות כי בדעת מישו להופכו לכה.

כל אלו יש בהם, לדעתי, כדי להראות כי סדר העדיפויות של בעלי הדירות לקוי.

יחד עם זאת, יש להכיר בעובדה שלנתבעת אין הסכמות אף לא בשיעור הקרוב לרוב הדרוש עפ"י חוק. משמעות הדבר היא ש מרביתם של בעלי הדירות בבית מצאו להעדיף את המצב הקיים. מהעדויות שבאו לפני עלה כי הדירות בבית לא הורחבו, וכי במתחם כולו נמצאות הדירות במצבן ובגודלן המקורי. לאור הפסיקה אשר הובאה לעיל לא נראה לי כי עקרון זה של בעלי הדירות עולה כדי התנגדות סתמית או כזו אשר נוגדת את עקרונות שיטת המשפט. התנגדויות אלו הגם שאינן תואמות את סדרי העדיף ויות הראויים לידי לא אוכל לומר לגביהן שהן התנגדויות פסולות, קנטרניות, סתמיות או התנגדות אחרת הנוגדת את שיטת המשפט ואיני רשאית להחליף את דעתם של בעלי הדירות בשיקול דעתי. לאור זאת, וכפי שנקבע בבירור בפסיקה אל לו למפקח לשקול את שיקוליהם של בעלי הדירות בבית ולהמיר דעתו בדעותיהם.

73. ויוטעם, לאור העובדה שהמחוקק קבע כי נדרש רוב מסוים וברור לצורך הרחבת דירה, והפסיקה, כאמור, לא מצאה לסטות מדרישת רוב זו אלא במקרים חריגים כפי שפורט לעיל. מצאתי כי אין זה מסמכותי לקבוע אם יש היגיון ברצון רוב בעלי הדירות בבית להותיר את המתחם כולו במצבו הארכיטקטוני הקיים - as is, ללא כל אפשרות להרחיב את הדירות או למגן, אם לאו. עניין הוא לבעלי הדירות באותו מתחם לענות בו. מוצאת אני כי זכותם של בעלי הדירות, ברוב הקבוע בחוק לפי העניין, לעצב את מראה ביתם.

בבואי לבחון את עמדות התובעים ומ ידת התאם תן לשיטה המשפטית שלנו (כהנחיית כב' השופטת וסרקרוג ב פס"ד נטלה) לא מצאתי בהן חוסר סבירות. התובעים מנמקים את עמדותיהם באופן ענייני העולה בקנה אחד עם המבנה הפיסי של הבית המשותף, ואפילו אינני חושבת כמותם לא מצאתי התנגדותם חסרת תוס לב במובן האמור לעיל.

23. יחד עם זאת, ממליצה אני בחום לצדדים לפעול לגיבושה של תוכנית כוללת אשר תאפשר בניית ממ"דים למתחם כולו למי מבעלי הדירות שליבו יהיה חפץ ולפעול על פי אותה התוכנית על מנת למגן עצמו.

דיון בסוגיות האחרות של כתב התביעה-

33. כתב התביעה עתר גם לסעדים הבאים: צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעת להשתלט ולתפוס באופן ייחודי חלקים מחצר הבית לרבות על דרך של הקמת מרפסת/ריצוף או גידור, וכן צו עשה אשר יורה לנתבעת לסגור פתח יציאה מדירתה אל החצר ויורה לה לסלק את מיטלטליה מהרכוש המשותף.

43. בכתב ההגנה אשר הוגש ע"י הנתבעת הבהירה הנתבעת כי היא חוזרת ב ה מבקשתה להקמת משטח דק בחצר. לאור הצהרתה זו, ניתן בזאת צו מניעה קבוע אשר אוסר על הנתבעת לבנות את משטח הדק נושא התביעה והיתר הבניה.

53. באשר ליתר הסעדים להם עתרו התובעים הכוללים: סגירת פתח היציאה לחצר וסילוק המיטלטלין מהחצר, הטענות והדרישות לסעדים אלו הועלו אך בכתב התביעה, אך נזנחו הן בעדויות והן בסיכומי התובעים. לאור זאת, לא מצאתי ליתן לגביהם כל סעד.

63. ניתן בזה, אפוא, פסק דין האוסר על הנתבעת לבנות ממ"ד בהתאם לתוכנית להיתר הבניה כל עוד לא יהיה בידיה הסכמות ברו ב הדרוש עפ"י חוק. אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים, ביחד ולחוד, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 6,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (10.2.13) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום יט' בטבת התשע"ד [2212.13]

העתקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין